

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제01절 청구의 원시적 병합>

[기출][2025-1-2]대여금 및 예비적 청구 소송에서 사문서의 진정성립 추정 및 예비적 병합의 심판순위에 따른 판결의 타당성

《[문제1] 2022. 5. 1. 甲은 乙에게 금 8,000만 원을 이자 없이 1년의 기한으로 대여하였는데, 기한이 지나도록 乙이 돈을 갚지 않아 甲은 乙에게 대여금의 상환을 독촉하였다. 2023. 10. 15.이 되어서 乙은 `2022. 5. 1.에 차용한 돈을 2024. 10. 31.까지 甲에게 지급하지 못할 때 甲의 요구가 있으면 乙이 소장하는 고려청자(이하 고려청자라 함)를 甲에게 양도한다.`라는 각서(이하 각서라 함)를 써 주었다. 고려청자는 5,000만 원 정도로 평가된다. 2024. 11. 5. 甲은 乙에게 돈을 갚으라고 하였고, 乙은 묵묵부답이었다. 2025. 2. 1. 甲은 乙을 상대로 금 8,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 소송에서 甲은 대여금 상환을 독촉하는 3통의 내용증명 우편을 증거로 제출하였다. (아래의 각 물음은 독립적이다.) (50점)

(물음2) 乙은 甲의 청구에 대하여 금전을 차용한 적이 없다고 하였다. 차용증이 없느냐는 재판장의 물음에 甲은 이사하던 중에 분실된 것 같다고 하면서 乙이 기명날인한 각서를 제출하였다. 이에 乙은 5,000만 원의 차용을 인정하였다. 다음 기일에 甲은 차용증을 찾았다고 증거로 제출하였고, 고려청자의 인도를 구하는 청구를 예비적으로 병합하였다. 乙은 뒤늦게 가져온 차용증은 위조일 수밖에 없다고 항변하였다. 재판장이 차용증에 있는 당사자들의 인영이 진정해 보인다고 하자, 乙은 자기의 기명날인이 맞긴 하지만 대여금은 여전히 5,000만 원이었다고 주장하였다. 이밖에 더 제출된 증거방법은 없었다. 마침내 법원은 乙은 甲에게 고려청자를 인도하라는 판결을 내렸다. 이 판결에 대하여 평가하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 대여금 및 예비적 청구 소송에서 사문서의 진정성립 추정 및 예비적 병합의 심판순위에 따른 판결의 타당성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙을 상대로 대여금 지급을 구하는 소송에서 각서와 차용증이 제출되고, 乙이 대여금 액수에 관하여 다투는 가운데 법원이 예비적으로 병합된 고려청자 인도청구를 인용한 상황이다. 쟁점으로 <증거의 진정성립과 재판상 자백의 효력, 그리고 법원이 당사자의 주장 범위를 넘어 예비적 청구를 인용할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 증거법상 사실인정의 기준과 변론주의 원칙에 따른 법원의 판단 범위를 설명한다.

II. 사문서의 진정성립 및 예비적 병합의 법리

1. 사문서의 진정성립의 추정

(1) 2단계의 추정

- 사문서의 진정성립을 인정하기 위해서는 날인행위의 진정함이 증명되어야 한다. "민사소송법 제358조"에 따라 문서에 있는 날인이 당사자의 인영과 일치함이 인정되면, 당사자 본인 또는 대리인의 의사에 기하여 날인된 것으로 사실상 추정된다. 이후 날인행위의 진정이 인정되면 당해 사문서 전체의 진정성립이 법률상 추정되는바, 이를 2단계의 추정이라고 한다.

(2) 추정의 반복 요건

- 일단 2단계의 추정이 형성되면 그 인용이 위조되었다거나 본인의 의사에 반하여 날인되었다는 사실, 또는 내용이 사후에 위조·변조되었다는 사실에 대한 주장·증명책임은 이를 다투는 자에게 전도된다. 단순한 부인이나 심증 제기만으로는 진정성립의 추정을 깨뜨릴 수 없으며, 제반 사정에 대한 엄격한 증명이 요구된다.

2. 예비적 병합의 심판순위와 처분권주의

(1) 주위적 청구 선험판단의 원칙

- 예비적 병합이란 원고가 양립할 수 없는 여러 청구를 제기하면서, 주위적 청구가 기각되거나 인용되지 않을 것에 대비하여 예비적 청구에 대한 심판을 구하는 소송 형태이다. 수소법원은 반드시 원고가 정한 심판 순위에 구속되므로, 주위적 청구에 대하여 먼저 심리·판단하여야 한다.

(2) 처분권주의와의 관계

- "민사소송법 제203조"의 처분권주의에 따라 법원은 원고가 제기한 주위적 청구의 당부를 먼저 밝혀야 하며, 주위적 청구가 전부 인용되는 경우에는 예비적 청구에 대하여 심판할 수 없다. 만약 주위적 청구가 정당함에도 이를 배척하거나 판단하지 않고 예비적 청구만을 인용한 판결은 심판순위를 위배하여 처분권주의에 정면으로 저촉된다.

III. 사안의 적용

1. 차용증의 진정성립 여부 및 주위적 청구의 판단

(1) 2단계의 추정에 따른 진정성립 인정

- 피고 乙은 차용증 상의 기명날인이 자신의 것임을 직접 시인하였다. 이에 따라 2단계의 추정이 작용하므로, 해당 차용증은 성립의 진정이 적법하게 추정된다.

(2) 乙의 위조 항변의 배척 및 주위적 청구의 인용 범위

- 乙은 뒤늦게 차용증이 위조되었다고 항변하였을 뿐, 날인이 도용되었다거나 사후 변조되었다는 점에 대하여 아무런 증거도 제출하지 못하여 반복요건을 충족하지 못하였다. 따라서 차용증에 적힌 대여금 8,000만 원은 진실한 요건사실로 인정되므로, 주위적 청구인 대여금 청구는 전액 인용되어야 마땅하다.

2. 예비적 청구 판단에 따른 판결의 위법성

(1) 심판순위 및 처분권주의 위배

- 원고 甲이 청구한 주위적 청구가 전액 인용되어야 하므로, 법원은 예비적 청구인 고려청자 인도 청구에 대하여는 심판을 진행할 수 없다. 그럼에도 주위적 청구를 판단하지 않거나 배척한 채 곧바로 고려청자 인도를 명한 것은 심판순위를 완전히 일탈한 재판이다.

(2) 대물변제 예약의 성부 판단 전제 흠결

- 가사 주위적 청구가 일부 기각된다 하더라도, 법원은 8,000만 원 중 인정되는 금액의 범위 내에서 이행을 명하고 예비적 청구를 판단해야 한다. 어떠한 경우라도 주위적 채무가 증명된 상태에서 주된 급부 대신 고려청자 인도를 명하는 것은 처분권주의에 정면으로 위배되어 부적법하다.

IV. 결론

1. 주위적 청구의 인용 정당성

- 피고 乙이 기명날인의 진정을 인정하고 위조 사실을 증명하지 못하였으므로, 2단계의 추정에 따라 8,000만 원 대여금 차용증의 진정성립이 인정되어 주위적 청구는 적법하게 인용되어야 한다.

2. 법원 판결의 위법성 및 결어

- 따라서 법원이 주위적 청구를 인용하지 않은 채 예비적 청구인 고려청자의 인도를 명한 판결은 사문서의 진정성립에 관한 법리를 오해하고 예비적 병합의 심판 순위 및 처분권주의를 심각하게 위반한 판결로서 전적으로 타당하지 않아 취소되어야 한다.